

1500733-15.2022.8.26.0617

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Beatriz Afonso Pascoal Queiroz

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/11/2022

... polícias, tal como ocorre, na maioria das vezes, com o tráfico de drogas.

9 - Não é das guardas municipais, mas sim das polícias, como regra, a competência para patrulhar supostos pontos de tráfico de drogas, realizar abordagens e revistas em indivíduos suspeitos da prática de tal crime ou ainda investigar denúncias anônimas relacionadas ao tráfico e outros delitos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

3ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, São José dos Campos - SP - cep 12246-260

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500733-15.2022.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500733-15.2022.8.26.0617

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDSON ALVES DE LIMA

Juíza de Direito: Dra. Beatriz Afonso Pascoal Queiroz

Vistos.

EDSON ALVES DE LIMA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, porque, no dia 30 de maio de 2022, por volta das 14h40, na Avenida Doutor Nelson D'Ávila, altura do numeral 865, Jardim São Dimas, em São José dos Campos, estaria trazendo consigo 22 invólucros de maconha, 03 microtubos plásticos de haxixe e 346 invólucros de crack, sem autorização.

Narra a denúncia que guardas civis realizavam patrulhamento de bicicleta e avistaram o acusado com uma pochete. Ao ver os policiais, ele fugiu, correndo por diversas ruas. Após acompanhamento, ele foi detido pelos guardas. Em revista pessoal, os guardas apreenderam a pochete, em cujo interior estavam as drogas, dois telefones celulares e R\$ 517,60, em dinheiro.

O acusado foi preso em flagrante e a prisão foi convertida em preventiva (fls. 48/51).

O acusado foi notificado e apresentou defesa prévia (fls. 95 e 99). A denúncia foi recebida em 07 de julho de 2022 (fls. 100). Durante a instrução, foram inquiridas testemunhas e o acusado foi interrogado.

Em memoriais, o promotor de justiça requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia. A defesa requereu seja declarada a nulidade do processo, sob a alegação de que a guarda municipal não tem competência para os atos que praticou. Subsidiariamente, requereu a absolvição do acusado por insuficiência de provas e, em caso de condenação, a fixação da pena mínima e o recurso em liberdade.

É o breve relatório.
Decido.

A pretensão punitiva é IMPROCEDENTE.

As drogas foram apreendidas e periciadas, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 28/29 e laudo de de exame químico-toxicológico de fls. 84/86, com resultado positivo para tetrahydrocannabinol (THC) e cocaína.

Em juízo, o guarda civil Leonardo disse que a sua equipe estava realizando patrulhamento em bicicletas em direção à região central quando surpreenderam o acusado em atitude suspeita. Ao vê-los, ele fugiu. Perderam-no de vista durante a fuga. Conseguiram localiza-lo e encontraram em sua posse uma pochete contendo dinheiro trocado (cerca de R\$ 500,00), drogas variadas (crack, haxixe e maconha) e dois telefones. A atitude suspeita consistiu na posse da pochete. Informalmente, ele admitiu que estava no tráfico. Foram hostilizados por moradores do local, que lhes atiraram pedras. Não agrediu o acusado. Durante a fuga, o acusado caiu diversas vezes. Não o conhecia. Quando viram o acusado, ele estava com outros indivíduos. Todos fugiram. O acusado ficou por último e por isso o abordaram. Foi o único que conseguiram alcançar. A pochete foi apreendida com o acusado. A pochete era maior que uma carteira. É comum fazerem tal tipo de abordagem. O acusado tentou escapar e por isso tentaram contê-lo, mas não o agrediram.

O guarda municipal Luiz Gustavo disse que disse que a sua equipe estava realizando patrulhamento em bicicletas quando viram o acusado. Ele começou a correr. Ele estava com uma bolsa transversal. Conseguiram alcança-lo. Na pochete, encontraram "muitas drogas", maconha e crack. Também havia dinheiro, mais de R\$ 500,00, e celular. O acusado nada alegou. Ele estava visivelmente alterado, possivelmente drogado. Outras pessoas também correram quando o acusado correu, mas só ele estava com a bolsa. Algumas pessoas se aproximaram e tentaram intimidá-los, jogando pedras. O acusado, ao ver que a comunidade estava a favor dele, tentou fugir. Rolou com Edson. Não o perderam de vista. Seguiu por um caminho e o seu parceiro por outro. O acusado tropeçou no meio do caminho. Não se lembra de ter dito na delegacia que o acusado confessou. Pelo seu dia a dia, conseguem ver o biotipo e de vestimentas de quem tem mais probabilidade de estar no crime e daí extrair a atitude suspeita. Não agrediram o acusado, mas "é evidente que se a pessoa reage fazem uso de força proporcional". A bolsa tinha de 15 a 20 cm.

A testemunha Tainá disse que estava passando pelo local e presenciou os fatos. Via frequentemente Edson pelo local. Viu Edson e várias outras pessoas correndo. Um dos guardas agarrou Edson e começou a agredi-lo. Na bolsinha de Edson não tinha nada, nem mesmo celular. Edson foi bastante agredido e ficou debilitado. Filmou a cena. Trabalha como manicure num salão no Jardim Paulista. Vê o acusado frequentemente a caminho do trabalho. Ele não confessou a traficância. Ele estava quase desacordado. O policial chegou a empurrá-lo para baixo do barranco. A bolsinha de Edson era bem pequena. Ele não reagiu. Não havia policiais militares no local. Não conhece Edson, mas costumava vê-lo passar a caminho do trabalho. Acha que ele trabalha numa oficina. O fato ocorreu no período da tarde.

Interrogado em juízo, o acusado disse que trabalhava na oficina Magda. É usuário de drogas e costumava ir ao local, na favela, para pegar maconha. Sabe que o passado o condena. Estava passando quando viu uma confusão. Viu várias pessoas correndo. Estava com uma bolsinha onde estavam seu RG, seu telefone e a chave do carro do cliente. Os guardas municipais bateram com a roda da bicicleta na sua perna e o mandaram parar. Apanhou e as coisas apagaram da sua mente. Soube pela médica que estava preso. Tem 25 anos. Foi pego por volta das 12h50. O fato não ocorreu 14h50. Ficou bastante tempo no hospital antes de ir para a delegacia. Estava voltando porque tinha que recomeçar a trabalhar.

O laudo de exame de corpo de delito constatou que o acusado sofreu lesões corporais de natureza leve, consistentes em "escoriações com crostas hemáticas recentes em face à esquerda, ambos os joelhos e na mão direita" (fls. 137/138).

Pela defesa, foi juntado um vídeo com imagens do fato (fls. 123/124).

A abordagem do acusado, pelos guardas municipais, foi ilegal. Eles abordaram o acusado porque entenderam que ele estavam em "atitude suspeita", por estar com uma pochete e por ter, juntamente com outras pessoas, corrido. Seja como for, eventual delito não era flagrante e os eles não poderiam ter agido como se fossem policiais.

A Constituição Federal atribui à Guarda Municipal a competência para a proteção do patrimônio municipal, não lhe sendo possível atuar em substituição à polícia de investigação ou ostensiva, em situações em que o delito não é flagrante.

A atuação em desconformidade com a Constituição configura a ilegalidade das provas obtidas.

Nesse sentido, decidiu recentemente o C. STJ (Recurso especial n. 1977119 - SP (2021/0391446-0); Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz; Julgamento: 16 de agosto de 2022):

"RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ATUAÇÃO DAS GUARDAS MUNICIPAIS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CLARA, DIRETA E IMEDIATA COM A TUTELA DOS BENS, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES MUNICIPAIS. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ILÍCITA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 157 E 244 DO CPP. RECURSO PROVIDO.

1 - A Constituição Federal de 1988 não atribui à guarda municipal atividades ostensivas típicas de polícia militar ou investigativas de polícia civil, como se fossem verdadeiras "polícias municipais", mas tão somente de proteção do patrimônio municipal, nele incluídos os seus bens, serviços e instalações. A exclusão das guardas municipais do rol de órgãos encarregados de promover a segurança pública (incisos do art. 144 da Constituição) decorreu de opção expressa do legislador constituinte - apesar das investidas em contrário - por não incluir no texto constitucional nenhuma forma de polícia municipal.

2 - Tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil - em contrapartida à possibilidade de exercerem a força pública e o monopólio estatal da violência - estão sujeitas a rígido controle correcional externo do Ministério Público (art. 129, VII, CF) e do Poder Judiciário (respectivamente da Justiça Militar e da Justiça Estadual). Já as guardas municipais - apesar da sua relevância - não estão sujeitas a nenhum controle correcional externo do Ministério Público nem do Poder Judiciário. É de ser ver com espanto, em um Estado Democrático de Direito, uma força pública imune a tais formas de fiscalização, a corroborar, mais uma vez, a decisão conscientemente tomada pelo Poder Constituinte originário quando restringiu as balizas de atuação das guardas municipais à vigilância do patrimônio municipal.

3 - Não é preciso ser dotado de grande criatividade para imaginar - em um país com suas conhecidas mazelas estruturais e culturais - o potencial caótico de se autorizar que cada um dos 5.570 municípios brasileiros tenha sua própria polícia, subordinada apenas ao comando do prefeito local e insubmissa a qualquer controle

externo. Ora, se mesmo no modelo de policiamento sujeito a controle externo do Ministério Público e concentrado em apenas 26 estados e um Distrito Federal já se encontram dificuldades de contenção e responsabilização por eventuais abusos na atividade policial, é fácil identificar o exponencial aumento de riscos e obstáculos à fiscalização caso se permita a organização de polícias locais nos 5.570 municípios brasileiros.

4 - A exemplificar o patente desvirtuamento das guardas municipais na atualidade, cabe registrar que muitas delas estão alterando suas denominações para “Polícia Municipal”. Ademais, inúmeros municípios pelo país afora – alguns até mesmo de porte bastante diminuto – estão equipando as suas guardas com fuzis, equipamentos de uso bélico, de alto poder letal e de uso exclusivo das Forças Armadas.

5 - A adequada interpretação do art. 244 do CPP é a de que a fundada suspeita de posse de corpo de delito é um requisito necessário, mas não suficiente, por si só, para autorizar a realização de busca pessoal, porque não é a qualquer cidadão que é dada a possibilidade de avaliar a presença dele; isto é, não é a todo indivíduo que cabe definir se, naquela oportunidade, a suspeita era fundada ou não e, por consequência, proceder a uma abordagem seguida de revista. Em outras palavras, mesmo se houver elementos concretos indicativos de fundada suspeita da posse de corpo de delito, a busca pessoal só será válida se realizada pelos agentes públicos com atribuição para tanto, a quem compete avaliar a presença de tais indícios e proceder à abordagem do suspeito.

6 - Ao dispor no art. 301 do CPP que “qualquer do povo poderá [...] prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito”, o legislador, tendo em conta o princípio da autodefesa da sociedade e a impossibilidade de que o Estado seja onipresente, contemplou apenas os flagrantes visíveis de plano, como, por exemplo, a situação de alguém que, no transporte público, flagra um indivíduo subtraindo sorrateiramente a carteira do bolso da calça de outrem e o detém. Diferente, porém, é a hipótese em que a situação de flagrante só é evidenciada após realizar atividades invasivas de polícia ostensiva ou investigativa como a busca pessoal ou domiciliar, uma vez que não é qualquer do povo que pode investigar, interrogar, abordar ou revistar seus semelhantes.

7 - Da mesma forma que os guardas municipais não são equiparáveis a policiais, também não são cidadãos comuns. Trata-se de agentes públicos com atribuição sui generis de segurança, pois, embora não elencados no rol de incisos do art. 144, caput, da Constituição, estão inseridos § 8º de tal dispositivo; dentro, portanto, do Título V, Capítulo III, da Constituição, que trata da segurança pública em sentido lato. Assim, se por um lado não podem realizar tudo o que é autorizado às polícias, por outro lado também não estão plenamente reduzidos à mera condição de “qualquer do povo”; são servidores públicos dotados do importante poder-dever de proteger o patrimônio municipal, nele incluídos os seus bens, serviços e instalações. 8 - É possível e recomendável, dessa forma, que exerçam a vigilância, por exemplo, de creches, escolas e postos de saúde municipais, de modo a garantir que não tenham sua estrutura física danificada ou subtraída por vândalos ou furtadores e, assim, permitir a continuidade da prestação do serviço público municipal correlato a tais instalações. Nessa esteira, podem realizar patrulhamento preventivo na cidade, mas sempre vinculados à finalidade específica de tutelar os bens, serviços e instalações municipais, e não de reprimir a criminalidade urbana ordinária, função esta cabível apenas às polícias, tal como ocorre, na maioria das vezes, com o tráfico de drogas.

9 - Não é das guardas municipais, mas sim das polícias, como regra, a competência para patrulhar supostos pontos de tráfico de drogas, realizar abordagens e revistas em indivíduos suspeitos da prática de tal crime ou ainda investigar denúncias anônimas relacionadas ao tráfico e outros delitos cuja prática não atinja de maneira clara, direta e imediata os bens, serviços e instalações municipais. Poderão, todavia, realizar busca pessoal em situações absolutamente excepcionais – e por isso interpretadas restritivamente – nas quais se demonstre concretamente haver clara, direta e imediata relação de pertinência com a finalidade da corporação, isto é, quando se tratar de instrumento imprescindível para a tutela dos bens, serviços e instalações municipais. Vale dizer, só é possível que as

guardas municipais realizem excepcionalmente busca pessoal se houver, além de justa causa para a medida (fundada suspeita de posse de corpo de delito), relação clara, direta e imediata com a necessidade de proteger a integridade dos bens e instalações ou assegurar a adequada execução dos serviços municipais, o que não se confunde com permissão para realizarem atividades ostensivas ou investigativas típicas das polícias militar e civil para combate da criminalidade urbana ordinária.

10 - Na hipótese dos autos, os guardas municipais estavam em patrulhamento quando depararam com o recorrente sentado na calçada, o qual, ao avistar a viatura, levantou-se e colocou uma sacola plástica na cintura. Por desconfiar de tal conduta, decidiram abordá-lo e, depois de revista pessoal, encontraram no referido recipiente certa quantidade de drogas que ensejou a prisão em flagrante delito.

11- Ainda que eventualmente se considerasse provável que a sacola ocultada pelo réu contivesse objetos ilícitos, não estavam os guardas municipais autorizados, naquela situação, a avaliar a presença da fundada suspeita e efetuar a busca pessoal no acusado. Caberia aos agentes municipais, apenas, naquele contexto totalmente alheio às suas atribuições, acionar os órgãos policiais para que realizassem a abordagem e revista do suspeito, o que, por não haver sido feito, macula a validade da diligência por violação do art. 244 do CPP e, por conseguinte, das provas colhidas em decorrência dela, nos termos do art. 157 do CPP, também contrariado na hipótese.

12 - Recurso especial provido".

Mesmo que a abordagem não tivesse sido ilegal, é duvidoso que o acusado estivesse na posse de drogas. O acusado negou a acusação e a sua versão foi corroborada pela testemunha Tainá, não havendo motivos para se atribuir valor superior à versão apresentada pelos guardas.

Assim, reconheço a nulidade das provas obtidas a partir da busca pessoal e, em consequência, absolvo o acusado.

Posto isso, declaro a nulidade das provas obtidas a partir da busca pessoal e ABSOLVO o acusado EDSON ALVES DE LIMA da acusação, o que faço nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

P. I. C.

Beatriz Afonso Pascoal Queiroz

Juíza de Direito